

刑法
No337

H22-1

(配点：3)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

甲は、知人である乙の家に遊びに行った際、乙の書斎の机の引き出し内に乙名義のキャッシュカード及びその暗証番号を記したメモがあるのを見付けた。甲は、乙の気付かないうちに同カードを使って預金を下ろしても、短時間で元の場所に戻しておけば発覚することはないだろうと考え、同カードを乙宅から持ち出した。その後、甲は、同カードを使って近くの金融機関の現金自動預払機から現金50万円の払戻しを受けた上、乙宅に戻り、同カードを持ち出してから約10分後に前記引き出し内に同カードを戻した。その際、甲は、同引き出し内に約20万円分の偽造通貨があるのに気付く、これを乙宅から持ち出した。その日の夜、甲は、その偽造通貨を真正の通貨と偽ってホテルでの宿泊代金の支払に使うこととし、Aホテルの従業員丙に宿泊を申し込み、偽造通貨であることを秘したまま、その偽造通貨で宿泊代金をあらかじめ支払って宿泊した。丙は、偽造通貨であることに気付いていれば、甲を宿泊させることはなかった。また、甲は、Aホテルに宿泊中にマッサージチェアに偽造通貨を投入してマッサージを受け、さらに、自己が宿泊している客室備付けのドライヤーを自宅で使おうと思い、これを勝手に持ち帰った。

【記述】

- ア. 甲が乙名義のキャッシュカードを持ち出した行為については、窃盗罪は成立しない。
 イ. 甲が乙名義のキャッシュカードを使用して現金50万円の払戻しを受けた行為については、窃盗罪が成立する。
 ウ. 甲が偽造通貨で宿泊代金を丙に支払って宿泊した行為については、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、両罪は牽連犯となる。
 エ. 甲がマッサージチェアに偽造通貨を投入した行為については、偽造通貨行使罪は成立しない。
 オ. 甲がドライヤーを持ち帰った行為については、横領罪が成立する。

No337

犯罪の成立①

正答率

H22-1

正解

ア 2

イ 1

ウ 2

エ 2

オ 2

49%

ア 誤っている

本記述では、甲に乙名義のキャッシュカードを元に戻す意思がある場合、甲に不法領得の意思が認められず、窃盗罪（235条）が成立しないのではないかが問題となる。この点、窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思が必要であり、不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用若しくは処分する意思をいう（大判大4.5.21）。本事例では、まず、甲は、持ち出したキャッシュカードを使って近くの金融機関の現金自動預払機から現金を払い戻そうとしているのであるから、キャッシュカードの経済的用法に従い利用若しくは処分する意思があることは明らかである。では、甲に権利者を排除する意思が認められるかが問題となる。可罰的な権利者排除の意思としての不法領得の意思の判断にあたっては、現代における物の利用価値の重要性を考慮すれば、その内容は、一般的に権利者が許容しないであろう程度の態様で利用する意思とすべきである。この点、キャッシュカードは、現金を現金自動預払機から引き出せる点に重要な意味があり、経済的価値を有する財物である。そのため、キャッシュカードの所有者は、他人が無断でキャッシュカードを持ち出して現金を引き出すことを容認しないと考えられる。そうすると、甲が乙名義のキャッシュカードを元に戻す意思があっても、現金を引き出す目的で無断で持ち出すことは、権利者を排除する意思に基づくものと認められる。よって、甲に不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立する。なお、経済的価値を有する会社の機密資料や住民基本台帳閲覧用マイクロフィルムをコピー目的で持ち出した事案において、裁判例は、管理者が、高い経済的価値を有する財物を無断で持ち出すことを容認していないということなどを理由に、不法領得の意思を認めている（東京地判昭59.6.28（百選Ⅱ33事件）、札幌地判平5.6.28）。

イ 正しい

本記述では、甲が乙名義のキャッシュカードを使って金融機関の現金自動預払機から現金50万円の払戻しを受けた場合、甲が乙宅からキャッシュカードを持ち出した行為に窃盗罪（235条）が成立するのとは別に、現金自動預払機からの現金の払戻しを受けた行為についても窃盗罪が成立するかが問題となる。この点、窃取したキャッシュカードを使って金融機関の現金自動預払機から現金の払戻しを受ける行為は、キャッシュカードについて事実上の処分をしたにとどまる場合と異なり、第三者である金融機関に対する関係において新たな法益侵害を伴うものである。本事例では、乙に対するキャッシュカードの窃盗罪のほかに、甲はキャッシュカードを利用して現金自動預払機の現金の払戻しを受けたことにより、現金自動預払機の管理者の意思に反し、現金を自己の支配下に移したものであって、新たに金融機関の現金に対する占有を侵害しているので、窃盗罪が別個に成立する。よって、現金自動預払機から現金の払戻しを受けた行為についても、甲に窃盗罪が成立する。なお、本事例と同様に窃取したキャッシュカードを使って金融機関の現金自動預払機から現金の払戻しを受けた事案において、裁判例は、第三者である金融機関に対する関係において新たな法益侵害を伴うものであるという理由により、現金の窃盗罪が別個に成立するとしている（東京高判昭55.3.3）。

ウ 誤っている

本記述では、甲が偽造通貨で宿泊代金を支払った行為について、甲に偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立するかが問題となる。この点、偽造した銀行券を本物と思わせて金員を騙し取った事案において、判例は、偽造通貨を行使し、よって財物を不正に領得した場合には、偽造通貨行使罪は成立するが、財物領得行為は偽造通貨行使の中に包含され、別に犯罪を構成するものではないとして、詐欺罪の成立を否定している（大判明43.6.30）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、

通貨を行使するときは一般に詐欺的行為が随伴するのであるから、偽造通貨行使罪の構成要件は詐欺罪を予定しているということや、偽造通貨行使罪の法定刑が著しく重いことから、詐欺罪に当たる行為は、本罪において評価し尽くされ、不可罰の事後行為に当たるということを挙げている。本事例では、甲は、偽造通貨を行使して、Aホテルから財物を不正に領得したのではなく、宿泊サービスという財産上の利益を得たものであるが、上記判例と同様に考えることができる。よって、甲に偽造通貨行使罪は成立するが詐欺罪は成立しない。

エ 誤っている

本記述では、甲が偽造通貨を機械に投入する行為が、「行使」(148条2項)に当たるかが問題となる。この点、「行使」とは、偽造通貨を真正な通貨として流通に置くことをいう。ここで、流通に置くとは、偽造通貨を自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽造通貨を真貨と誤信し得る状態に置くことをいう。本事例では、甲は偽造通貨をマッサージチェアに投入している。「偽造」とは、権限のないものが通貨に似た外観のものを作成することをいい、一般人をして真正の通貨と誤認せしめる程度のものであることが必要であるから、偽造通貨を機械に投入すれば、真貨と混ざり、一般人が見て、偽造通貨が真貨と誤信される可能性がある。そうすると、甲の行為は、偽造通貨を真正な通貨として流通に置いたといえ、「行使」に当たる。よって、甲に偽造通貨行使罪が成立する。なお、偽造通貨を自動販売機に投入した事案において、裁判例は、自動販売機に偽造通貨を投入する行為は「行使」に当たるとしている(東京高判昭53.3.22)。

オ 誤っている

本記述では、Aホテルの客室備付けのドライヤーを宿泊客甲が勝手に持ち帰った場合、Aホテルにドライヤーの占有(事実上の支配)が認められれば、甲に横領罪ではなく、窃盗罪が成立するので、甲とAホテルのいずれにドライヤーの占有が認められるかが問題となる。この点、財物が来店した客などに提供された場合には、提供の場所が提供者の包括的に支配する場所であることや、そのような状況を前提に財物が提供されたことからすれば、被提供者に許されるのは提供者の監視の下における財物の利用のみであり、被提供者は提供者による財物握持の手段・方法にすぎず財物に対する実質的な支配は排除されているものとされる。本事例においては、Aホテルの客室備付けのドライヤーは、Aホテルが支配する場所に備え付けられていることから、甲はAホテルの監視の下でドライヤーを使用することしか許されておらず、甲のドライヤーに対する支配は実質的には排除されているといえる。そのため、ドライヤーの事実上の支配はAホテルにあり、甲ではなくAホテルにドライヤーの占有が認められる。そうであるとすれば、甲の行為は、Aホテルの占有を侵害するものといえ、「窃取」に当たる。よって、甲に横領罪ではなく窃盗罪が成立する。